

1501458-50.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO CÉSAR DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

RODRIGO CÉSAR DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 12 de julho de 2022, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1501458-50.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501458-50.2022.8.26.0537 Controle nº 1079/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO CÉSAR DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

RODRIGO CÉSAR DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 12 de julho de 2022, por

volta das 12:20 horas, na Rua Bethoven, altura do n.º 68, próximo à Rua Mozart, Bairro Casa Grande, adquiriu, guardava, tinha em depósito, entregou e forneceu, para consumo de terceiros, maconha, cocaína, e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 62/64). A prisão preventiva foi reexaminada em 30.09.22 (fls. 122/123) e mantida.

Foi apresentada defesa prévia (fls. 116/118), sendo recebida a denúncia em 30.09.22 (fls. 122/123). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo a desistência quanto à faltante. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dra. Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela reincidência, fixado regime fechado, afastada a redução do art. 33, §4.º e perda do dinheiro apreendido.

O defensor do réu requereu a absolvição ou em caso de eventual condenação, a redução do art. 33, §4.º por não ser reincidente específico, a fixação de regime aberto ou semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 18), o acusado negou a prática do crime. Disse que mora próximo ao local da prisão (a cerca de 500 metros). Falou que na manhã daquele dia foi até a padaria, onde consumiu gim e cerveja, e em seguida foi até a praça da Rua Bethoven para fumar maconha. Declarou que havia comprado maconha na noite do dia anterior, em uma "biqueira" no Bairro Portinari, e que quando foi abordado pelos policiais já havia consumido a droga. Afirmou que o local é um ponto de traficância, mas negou que estivesse traficando.

Em juízo, negou ter praticado o crime. Mora perto da Praça, estava no bar tomando cerveja, que fica na parte de cima. O ponto de tráfico é na parte de baixo. Informou que saiu do bar e desceu para a parte de baixo. Estava conversando com um rapaz (Diogo) e mais 4 pessoas, na parte de baixo e foi abordado. Tinha mais pessoas na praça com blusa do Brasil, não correu e foi abordado. Não estava com drogas. Trabalhava fazendo "bicos" como ajudante de pedreiro. Disse que estava entregando currículo e foi chamado para trabalhar depois de preso. Conhecia os policiais apenas de vista. É usuário de maconha. Tem condenação por roubo e já cumpriu a pena. Está há 8 anos na rua. A droga estava há uma distância de uns 10 metros, mandaram por a mão na cabeça e perguntaram de quem era o pacote. Tinha apenas R\$5,00 no seu bolso.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 02 e 04), disseram que diligenciaram ao local dos fatos a fim de apurarem uma denúncia anônima feita por telefone, que informava que um homem (pardo, magro, alto, trajando jaqueta de cor verde e amarela da seleção brasileira de futebol e calça jeans escura), estava traficando drogas na Rua Bethoven, n.º 68, próximo à Rua Mozart. Relataram que no local, uma praça, se depararam com o réu, que possuía as mesmas características informadas na denúncia anônima, e outro homem. Narraram que em dado momento observaram o réu se abaixar, pegar algo de um pneu em formato de vaso e entregar ao homem que estava próximo dele. Então, resolveram abordá-los. Declararam que conseguiram abordar o réu, pois aquele outro homem já havia se retirado do local, e que em busca pessoal no réu localizaram no bolso dele a quantia de R\$ 5,00. Afirmaram que em buscas no pneu que servia como vaso localizaram uma sacola plástica de cor verde, cujo interior continha 42 porções de maconha, 20 invólucros de cocaína e 20 pedras de "crack", todas embaladas e individualizadas. Falaram que o réu negou estar traficando as drogas. Informaram que no local somente se encontravam o réu e o homem que se evadiu no momento da abordagem.

Pedro (policial), em juízo, informou que receberam, na Delegacia, denúncia anônima de tráfico no local e que o homem estaria usando uma blusa verde e amarela.

Avistaram o réu, que estava com a roupa mencionada e próximo dele havia uma sacola com maconha, cocaína e "crack" (divididas em porções). A sacola estava há uma

distância de uns 2 metros do réu e o viram mexendo na sacola. O local é conhecido como ponto de tráfico. Não fizeram campana, mas no momento que chegaram viram o réu entregando a droga para um usuário. Havia R\$5,00 com o réu.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Marcos. O réu negou a prática do crime. No bolso do réu havia R\$5,00. Viram quando iam descer da viatura, o réu entregando a droga para o usuário, mas quando foram abordar este se evadiu. O réu já tinha passagem e negou o tráfico. Não conhecia o réu anteriormente. Não fizeram "campana" por já saberem da jaqueta da seleção brasileira. A sacola plástica verde estava há uma distância entre 2 a 5 metros do réu. Quando a viatura aparece na praça as pessoas se "espalham". Informou que o réu ficou surpreso e não tentou correr. Em poder do réu não havia anotações, apenas R\$5,00.

Eduarda (testemunha de defesa) narrou que conhece o réu há 3 meses da Praça. Sabe que o réu faz "bicos" de pedreiro e já jogou dominó com ele. No dia da prisão estava na Praça e viu os policiais abordando o réu. Antes o réu estava bebendo e fumando e ela lá jogando dominó. Não era o réu que estava traficando. O traficante era um "branquinho" com blusa cinza escuro, mas não sabe o nome. Acha que o réu estava com blusa verde. Havia em torno de 5 pessoas perto do réu quando foi abordado. Informou que estava jogando dominó e o réu chegou na Praça depois dela. Disse que o réu estava na Praça há uns 10 ou 15 minutos quando os policiais chegaram. O réu estava na parte de cima e ela na parte de baixo da Praça, mas dava para ver aquele, mas não tudo que fazia.

O réu nada disse contra os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

O fato de a testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA - Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade (fls. 144 - 42 porções de maconha, 20 invólucros de cocaína e 20 pedras de "crack") e a variedade (maconha, cocaína e "crack") das drogas apreendidas, aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que foi apreendido dinheiro, não sendo provada a sua procedência, a confissão informal aos policiais, bem como os depoimentos dos policiais, que presenciaram, inclusive, atos de mercancia, demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Há que se observar que a testemunha de defesa não inocenta o réu, posto que estava na parte de baixo e o réu na parte de cima da Praça e a mesma deixou claro que não viu tudo que o réu fazia, apenas a abordagem. Apesar de referida testemunha dizer que o traficante estava com camisa cinza, como todos sabem há troca de "turnos". É certo que se a testemunha estava jogando dominó, obviamente sua atenção está voltada para este e não sobre o que acontecia ao seu redor, tanto que disse que achava que o réu estava com camisa verde, quando o próprio réu admitiu que estava com a da seleção brasileira (verde e amarela) e que havia mais pessoas na Praça com a mesma camisa. Ademais, o réu não trouxe as testemunhas com as quais alegou que estava conversando e não no tráfico. O fato de estar com apenas R\$5,00 é irrelevante, pois caso tivesse vendido antes como alegado pela defesa, como se sabe há o "recolhe".

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (42 porções de maconha, 20 invólucros de cocaína e 20 pedras de "crack"), demonstram que se destinava ao tráfico.

Desta forma, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 07/12) e laudo definitivo (fls. 82/84). Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 41 - proc. 3504-31.2014 - pena julgada extinta em 21.05.18).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que "a lei regulará a individualização da pena" e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal).".

Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base para o tráfico em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado. Não é caso de aumento da pena-base diante da variedade de drogas, uma vez que no caso em tela a quantidade apreendida é pequena (nesta Comarca inferior a 100).

Aumento a pena de 1/6 pela reincidência.

O réu não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário) que são cumulativos, além de se dedicar a atividades criminosas, já que é reincidente. Irrelevante que o réu não seja reincidente específico, posto que a lei exige que seja primário.

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente por roubo (fls. 41 - proc. 3504-31.2014 - pena julgada extinta em 21.05.18), demonstrando que não foi um fato isolado em sua vida e sequer provou possuir ocupação lícita como mencionou com diversos registros em carteira de trabalho. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos diante do montante da pena e por ser reincidente.

Inaplicável o disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 12.07.22, pelo que

ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 11.11.24).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência (circunstância judicial agravante), não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO RODRIGO CÉSAR DOS SANTOS à pena de 5 (CINCO) ANOS e 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei n.º 8072/90, que o M.P não concordou com o recurso em liberdade, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita) e é incabível qualquer benefício, recomende-se na prisão em que se encontra.

Custas "ex lege" (Lei n.º 11.608/03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 134 e 144) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Em relação à sacola plástica "tipo supermercado" da marca "Bioplástica Verde Central Plast Embalagens", apreendida (fls. 144) e já periciada (fls. 131/132), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 65) e providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, § 4.º, da Lei n.º 11343/06).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 26 de outubro de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA